

1500086-77.2022.8.26.0598

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... para majorar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado sob pena de bis in idem. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Inexistência de informações de que se dedique a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa. Presença dos requisitos do tráfico privilegiado. Afastamento da hediondez do tráfico privilegiado. Desnecessidade de imposição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500086-77.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-77.2022.8.26.0598

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HARRISON HENRIQUE PINHEIRO MENDONÇA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de HARRISON HENRIQUE PINHEIRO MENDONÇA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 13 de fevereiro de 2022, às 05h50min, na Rua Rio Branco, n. 132, Centro, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 18 porções de cocaína, com peso líquido de 8,07 gramas, 19 porções de crack, com peso líquido de 3,88 gramas, e 01 porção de maconha, com peso líquido de 6,46 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando visualizaram o acusado correndo pela via pública. O comportamento do acusado chamou a atenção dos policiais militares, que decidiram pela abordagem. Antes de ser abordado, Harrison arremessou um invólucro plástico que trazia consigo. Tal objeto foi apreendido e dentro dele foram localizados diversos pinos de cocaína. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram mais porções de cocaína em poder do acusado, bem como as porções de crack e maconha supracitadas, além da quantia em dinheiro de R\$ 42,00. O acusado confessou a

propriedade das drogas e o propósito de tráfico, bem como esclareceu que o dinheiro que trazia consigo era produto do comércio ilícito. Além disso, o tráfico de drogas ocorreu nas proximidades e também no interior do Clube Ponte Preta, estabelecimento recreativo e esportivo onde ocorria uma festa naquela oportunidade.

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 01/04.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 66/67).

Notificado (fl. 108), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 109.

Recebida a denúncia em 19 de abril de 2022 (fls. 110/111), sendo designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), pelos depoimentos (fls. 05/06), pelo interrogatório (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelos autos de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 35/43) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 89/93).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Ricardo Aparecido Fantim David, em sede policial, disse que é policial militar, que nesta data estava em patrulhamento de rotina com o parceiro policial pela Avenida Prudente de Moraes, em Barra Bonita/SP, quando visualizou indivíduo correndo pela via pública em atitude suspeita. Narra que quando o indivíduo visualizou a aproximação da viatura empreendeu fuga do local, sendo alcançado alguns metros há diante. No momento da abordagem o indiciado, posteriormente identificado como Harrison Henrique Pinheiro Mendonça, jogou um saco plástico por cima de um muro de uma residência próxima, contendo pinos de cocaína. Em revista pessoal foram encontrados no bolso da blusa de Harrison mais pinos contendo cocaína, bem como R\$ 44,00 no bolso da bermuda. Harrison vestia uma pochete, que em seu interior foram localizados 2 pinos de cocaína, uma porção de crack e outra de maconha, a qual afirmou que era para consumo próprio. Ao ser inquirido, Harrison afirmou que estava ocorrendo uma festa no Clube Ponte Preta, onde estava vendendo os entorpecentes no local. Diante exposto, conduziu o indiciado a este plantão policial para noticiar os fatos, juntamente aos entorpecentes que foram encaminhados para constatação pericial (fl. 05). Em juízo confirmou o dito em solo policial dizendo que estava tendo uma festa no clube e vinham patrulhando as proximidades, quando viram harrison ele estava correndo e foi abordado. Ele tentou dispensar sobre o muro da abordagem um invólucro branco, ele se abriu e havia lá 16 pinos. Em busca pessoal localizou 44 reais, uma pochete com 2 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e uma porção de maconha e ainda 20 reais. Ele disse que estava vendendo no baile na rua prudente de morais. Vendia cada pino a 20 reais e a maconha era para uso. Falou que o dinheiro era proveniente da venda dos entorpecentes. Já o conhecia da época em que era menor de idade.

No mesmo sentido, a testemunha Thiago Regis Sanguini, também policial militar, em sede policial, ratificou o esclarecido pela testemunha acima (fl. 06).

Em juízo contou que estavam em patrulhamento de rotina e harrison assim que viu a viatura começou a correr, logo antes da abordagem ele tentou dispensar uma sacola branca dentro de uma casa, mas ela se abriu e caiu sobre o chão 16 pinos de cocaína, ele tinha consigo 44 reais e mais uma pochete com cocaína, crack e mais 20 reais. Ele disse que estava em um baile e que ali vendeu drogas, sendo essa a procedência do dinheiro. A maconha era para uso próprio. A rua é ponto de venda de drogas.

O réu, em sede policial, contou que tem 19 anos de idade. Que sua família não sabe de sua condução a Delegacia de Polícia e não sabe declinar nenhum telefone de contato. Que já foi apreendido na Fundação CASA pelo ato infracional de tráfico de drogas. Que não tem advogado constituído. Que em relação aos fatos tem a dizer:

Confessa que estava portando as drogas quando foi abordado pelos policiais militares. Disse que estava dando um "peão" quando foi abordado pelos militares. Que estava com as drogas consigo e venderia as mesmas por dez reais a porção de cocaína e dez reais a porção de "crack". Que o dinheiro localizado consigo é oriundo da venda das drogas. Que não sabe dizer quanto ganharia pela venda das drogas pois sequer sabe quantas porções trazia consigo. Que não teve qualquer problema com os policiais (fls. 07/08).

Em seu interrogatório, o Réu disse que estava no baile e encontrou um colga seu, seu amigo lhe passou essa droga para vender, ia ganhar um pouco da droga pois é usuário. Estava com os 42 reais, era de droga que já tinha vendido na noite. Está arrependido e gostaria de ter mais uma oportunidade para voltar para casa. Mora com a irmã e ajuda em casa, está fazendo falta. Trabalhava de pintor e tirava 50 reais por dia. Brigou com a sua mãe que também é usuária, por isso foi morar com a irmã. Aceitou vender as drogas para poder usar um pouco e não ter que compra-las. É importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, necessário analisar a responsabilidade criminal do denunciado, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, dúvidas não pairam sobre a apreensão da droga e sua titularidade, sendo certo que, nas circunstâncias em que encontradas as substâncias ilícitas, sua quantidade, variedade e local de apreensão, resulta indubitosa a conclusão de que não se destinavam tão somente ao uso pessoal do réu, ainda mais porque estavam acompanhadas de dinheiro e já havia denúncia de atividade de venda no local em questão.

Ainda, ressalto que que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de cocaína é em média 3,8 gramas por dia, crack é de até 15 pedras por dia (entre 11 e 16), sendo que cada pedra varia de 0,1 a 1,5 gramas e de maconha é de em média 2,5 gramas, assim, as quantias e em especial, a variedade apreendida nos autos indicam a mercancia e não o uso.

Outrossim, o réu possuía dinheiro em notas trocadas (R\$64,00), cuja origem lícita não foi comprovada.

Comprovado, assim, o agir típico, em sua materialidade e autoria.

O fato imputado ao Réu também é antijurídico, vez que não restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP. Ele também é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhes eram exigidas condutas diversas das que exerceu. Presente, assim, a sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem qualificadoras ou privilégios a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o crime ocorreu nas proximidades e também no interior do Clube Ponte Preta, estabelecimento recreativo e esportivo onde ocorria uma festa, conforme prova oral colhida em audiência. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1. Recurso ministerial. Pleito objetivando a majoração da pena-base, o afastamento do tráfico privilegiado, o regime inicial fechado e inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Descabimento. Quantidade não elevada de drogas. Impossibilidade da utilização da quantidade e natureza dos entorpecentes para majorar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado sob pena de bis in idem. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Inexistência de informações de que se dedique a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa. Presença dos requisitos do tráfico privilegiado. Afastamento da hediondez do tráfico privilegiado. Desnecessidade de imposição de regime mais severo. 2. Recurso defensivo. Pleito objetivando o afastamento da causa de aumento dada pelo art. 40, III, da Lei de Drogas e a fixação do regime aberto. Causa de aumento demonstrada. Presença de estabelecimento de ensino nas imediações do local onde o tráfico era realizado. Comprovação pela prova oral e pela juntada de mapa. Desnecessidade de realização de perícia. Causa de aumento de índole objetiva. Desnecessidade de comprovação de que algum estudante tenha sido atingido pela conduta ilícita praticada pelo réu. Precedentes do STJ. Cabimento do regime aberto. Acusado primário e pena fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502519-54.2019.8.26.0535; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (grifei).

Aplica-se ainda a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Na espécie, o Réu é primário e de bons antecedentes, uma vez que, com exceção deste processo, jamais teve qualquer inquérito policial ou ação penal instaurados contra si (fls. 50/52).

Também não restou provado que se dedicava a atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

De outro lado, sua passagem infracional (fl. 53) ainda que não seja considerada

crime e que não seja recente, apesar de não ser suficiente para afastar a aplicação da figura privilegiada, pois não indica dedicação atual a qualquer atividade criminosa, deve fixar a fração de diminuição em seu patamar intermediário (1/2), pois demonstram que não é a primeira incursão ilícita do réu, ademais a diversidade das drogas apreendidas assim o recomenda.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. Fls. 50-52). A quantidade de drogas, embora razoável a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie, apesar de várias porções, a quantidade em gramas líquidas, não é expressiva. Assim, considero que, para agravar a pena com base no art. 42, LD, tanto a quantidade (que no caso não é expressiva), quanto a natureza da droga, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido:

Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada -TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não há agravante e se verificam as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) - eis que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos quando dos fatos narrados na denúncia e atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Dessa forma, observado o disposto na Súmula nº 231, STJ, fixo a pena provisória em seu mínimo legal, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual de 1/2, a pena é reduzida a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa.

Como o crime ocorreu nas imediações de estabelecimento recreativo e esportivo onde ocorria uma festa, tendo grande circulação de pessoas, a pena deve ser exasperada em 1/6, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 11 meses e 291 dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 CP, e do art. 42, Lei nº 11.343/06, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar.

No caso, o Réu está preso desde 13/02/2022, portanto, a 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, contudo, como o regime inicial foi fixado no aberto, não há possibilidade de progressão, mas apenas e tão-somente de abatimento do restante a ser cumprido, seja como pena privativa de liberdade, seja como pena restritiva de direitos.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, sem prejuízo à normal jornada de trabalho do Réu.

Incabível, tendo em vista a disposição contida no art. 77, III, CP.

Considerando a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, considerando a primariedade do Réu, tendo em vista que inexistente manifesto risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal e que as ordens pública e econômica não se encontram em risco, desnecessária a manutenção da prisão cautelar do Réu, uma vez que insuficientes os requisitos para tanto, podendo, assim, recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Por outro lado, dada a natureza hedionda da infração, que se mantém mesmo quando aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, conforme preceitua a Súmula nº 512 do Superior Tribunal de Justiça, as condições de quem a praticou e a grande necessidade de combate e prevenção ao tráfico de drogas, entendendo ser oportuna a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, na forma do art. 319, CPP, e sem prejuízo das demais condições impostas no regime de cumprimento em que estiver inserto, deve o Réu, durante todo o período de cumprimento da pena:

- (i) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
- (ii) não frequentar locais em que possa ter acesso a drogas;
- (iii) não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; e
- (iv) manter este Juízo informado acerca de seu endereço.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, condenar o Réu HARRISON HENRIQUE PINHEIRO MENDONÇA como incurso no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos, e 291 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Desnecessária a prisão cautelar do Réu, posto que insuficientes os requisitos para tanto, podendo, assim, recorrer em liberdade (art. 387, §1º, CPP). Contudo, aplico as medidas cautelares retro determinadas. Assim, expeça-se alvará de soltura, com as ressalvas de praxe.

Com o trânsito em julgado:

comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, ao IIRG e anote-se o nome do Réu no rol dos culpados;

intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;

expeça-se guia de recolhimento definitivo;

tendo em vista que a Lei nº 12.961/2014, que revogou o art. 58, § 1º, Lei nº 11.343/06 e passou a determinar a destruição da droga, por meio de incineração, quando do recebimento do flagrante (art. 50, § 3º, Lei nº 11.343/06, com a nova redação), só entrou em vigor em 04 de abril de 2014, após o flagrante, portanto, permaneço determinando a destruição da droga, guardando-se pequena amostra para contraprova;

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

expeça-se a certidão de honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.